

1502359-31.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502359-31.2021.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502359-31.2021.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

THIAGO ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, menor de 21 anos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 3 de outubro de 2021, por volta das 08h40min, na Rua Carlos Ângelo Mation, altura do nº 1.400, Jardim Tamoio, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo, para fim de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que causam dependência

física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, Thiago recebeu de terceiros uma sacola plástica contendo diversas porções de drogas distintas. O acusado também ajustou que permaneceria no local dos fatos para vender tais entorpecentes durante o período noturno, até que outra pessoa tomasse seu lugar.

Assim, com esse objetivo, o réu se dirigiu ao endereço acima mencionado, conhecido como ponto de tráfico, e permaneceu comercializando o tóxico.

Enquanto estava no local, Thiago foi surpreendido por uma viatura da Guarda Municipal que realizava patrulhamento nas imediações. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado tentou fugir em desabalada carreira, levando consigo a sacola contendo as drogas. No entanto, acabou caindo ao solo e acabou preso.

Em revista pessoal, os agentes municipais apreenderam, no interior da sacola, 82 porções de maconha, 18 porções de cocaína, 26 porções de "crack", 30 frascos contendo lança-perfume e 29 porções de "k2", além da quantia de R\$ 90,00 em cédulas de pequeno valor.

Instado a respeito dos fatos, o acusado admitiu que estava vendendo drogas.

Assim, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, em preliminar, arguiu a ilicitude das provas, ante a ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais e violação ao disposto no artigo 144 da Constituição Federal. Alegou, ainda, ausência de fundada suspeita para revista pessoal, com flagrante inobservância do previsto no § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal. No mérito, bateu-se por absolvição, sob os fundamentos de coação moral irresistível, vez que traficava para pagar dívida com traficantes; e insuficiência probatória para o édito condenatório. Em caso de entendimento diverso, requereu fixação pena base no mínimo legal; reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa; aplicação do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, vez que não há prova que o réu integre associação criminosa; imposição de regime inicial diverso do fechado; substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

Afasto as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

Não há falar em ilegalidade na atuação dos guardas municipais quando da prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, "in casu", não houve qualquer investigação policial exercida pelos guardas municipais, mas sim situação de flagrância, o que autoriza a prisão, vez que o tráfico de substância entorpecente é crime de natureza permanente. Assim, permanecendo o agente em situação de flagrância, não há qualquer ilicitude no fato dos guardas municipais terem dado voz de prisão ao acusado e apreendido a droga. Ademais, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante.

E ainda que se desconsiderasse o enquadramento dos guardas municipais como "autoridades policiais" - a quem cabe o dever de efetuar prisões em flagrante - permaneceria a eles a possibilidade de realizá-las, uma vez que o dispositivo legal acima referido permite, de forma expressa, tal faculdade a "qualquer do povo".

Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "Tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Nulidade do auto de prisão. Flagrante realizado por guardas municipais. Possibilidade. Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal.

Mácula inexistente. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes". (HC nº 296.728/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/09/2014).

Note-se, outrossim, que a prisão foi devidamente comunicada à autoridade judiciária competente, que lavrou o auto de prisão respectivo e firmou a nota de culpa ao réu, ratificando e convalidando, portanto, os atos praticados pelos agentes municipais. Importa observar, por oportuno, que não obstante o disposto no artigo 144, § 8º, da Carta Magna, prever, como função da guarda municipal – relativamente ao município – a “proteção de seus bens, serviços e instalações”, inexistente falar em proibição de que prendam em flagrante pessoas suspeitas de praticarem crimes, bem como que apreendam bens relacionados aos delitos.

Entendimento contrário, como quer a defesa, implicaria equivocada proibição às guardas municipais, sem qualquer base normativa ou justificativa razoável. Também não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos guardas municipais.

Sendo assim, quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que “em processo penal, vigoram os princípios de que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)’” (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Afastadas as preliminares, no mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 14/16 e 66/68), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu preferiu o silêncio. Em Juízo, confessou, afirmando

que, na data dos fatos, estava na posse das drogas para vender e quitar uma dívida de tráfico de uma tia usuária de "crack".

Inegável o valor da confissão judicial, que somente perderá seu valor se desmentida pelas demais provas, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso em tela.

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Jonas Botelho Marestoni e Silas Ferreira Braga, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas e do dinheiro em poder do réu, em local conhecido como ponto de tráfico. Relataram, ainda, que o acusado confessou a traficância.

Como se vê, as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação. Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Cumprir observar, outrossim, que a alegação do réu - ter sido ameaçado e obrigado por traficantes a praticar o delito (coação moral irresistível) - não merece guarida.

Com efeito, para a configuração da excludente da coação moral irresistível, exige-se que a intimidação seja concreta, insuperável, invencível, contra a qual não se possa opor atitude capaz de neutralizá-la. Não é o que ocorre in casu.

Bem esclarece o festejado Miguel Reale Júnior: "(...) a ofensa que se ameaça realizar deve ser certa, ou seja, ofensa que se sabe poder o autor da ameaça cumprir e não hipótese de factibilidade duvidosa. É próprio do conceito de ameaça a seriedade, e esta seriedade completa-se com a exigência de ser certa a ofensa. A ofensa deve, também, ser grave, promessa de prejuízo substancial a direito do agente, a ponto de constituir elemento indicador da preferência em favor da prática do delito" (cf. Instituições de Direito Penal, 2ª ed., Forense, 2006, v. 1, pág. 198).

Assim, a simples alegação do acusado de que sofreu ameaça por parte dos indivíduos, não é suficiente para demonstrar a aludida excludente.

De fato, alegando um fato (coação irresistível), que exclui a sua culpabilidade,

cabe ao coacto o ônus de prova-lo (Código de Processo Penal, artigo 156, 1ª parte; Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, págs. 9-11; RT, 813/598 e 900/632).

Quando não bastasse, “A coação irresistível deve ser cumpridamente demonstrada por quem a alega, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus: bastaria que dissessem terem sido coagidos, para conseguirem absolvição” (JTACrim, 94/137).

Mas não é tudo. “Para invocar a coação, como causa de exclusão de culpabilidade (art. 22 do CP), é mister que a vontade do sujeito passivo tenha sido obliterada por força invencível de outrem” (RT, 784/621).

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu THIAGO ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base acima do patamar mínimo, no percentual de 1/5 (um quinto), somando 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista a quantidade e variedade de tóxico apreendida em poder do réu.

Note-se que a “Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006” (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-094, 15/05/2012).

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão, a pena retorna ao mínimo previsto em lei.

Em que pese a quantidade de droga apreendida, é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que se trata de réu primário, portador de bons antecedentes, relativamente menor, não restando comprovada sua dedicação ao crime.

Assim, reduzo a sanção em 1/2 (metade), resultando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime aberto.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Assim, fica o réu THIAGO ALVES DA COSTA, condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 08 de fevereiro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito